

刑法
No80

H22-4

(配点：2)

月 日

月 日

正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 相手方による侵害を予期している者が、その侵害から自己の権利を防衛するには侵害に先んじて相手方に加害行為をすることが効果的な状況において、相手方による侵害が間近に押し迫る前に加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地はない。
2. 相手方による侵害を予期していた者が、それを避けずにその侵害に臨み、予期された侵害に対し反撃した場合、正当防衛が成立する余地はない。
3. 相手方を挑発して相手方による侵害を自ら招いた者が、それに対し反撃した場合、正当防衛が成立する余地はない。
4. いわゆるけんか闘争状態にある者が、相手方に対して加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地はない。
5. 相手方による侵害に対し反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立する余地はない。

1 正しい

本記述では、相手方による侵害を予期している者が、その侵害が間近に押し迫る前に、防衛に効果的な加害行為を行った場合、正当防衛が成立する余地があるかが問題となる。この点、「急迫」（36条1項）とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいう（最判昭46.11.16）。そうすると、相手方による侵害が間近に押し迫る前は、侵害の「急迫」性の要件を満たさない。よって、侵害が間近に押し迫る前にした加害行為には、正当防衛が成立する余地はない。

2 誤っている

最決昭52.7.21（百選I〔第7版〕23事件）。本記述では、相手方による侵害を予期していた者が、予期した侵害を避けて反撃した場合、正当防衛が成立する余地があるかが問題となる。この点、判例は、「単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を満たさない」としているが、他方、「当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではない」としている。その理由として、判例は、36条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課す趣旨ではないという点を挙げている。よって、相手方による侵害を予期していた者が、予期した侵害を避けて反撃した場合、正当防衛が成立する余地がある。

3 誤っている

大判大3.9.25、最決平20.5.20（百選I26事件）。本記述では、相手方を挑発して相手方による侵害を自ら招いた者が反撃行為をした場合、正当防衛が成立する余地があるかが問題となる。この点、判例は、不正の行為により自ら侵害を受けるに至った場合においてもなお正当防衛を行使することを妨げないとしている（大判大3.9.25）。また、近時の判例は、相手方の攻撃が「被告人の暴行に触発された、その直後における近接した場所での一連、一体の事態ということができ、被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえる」場合について、相手方の「攻撃が被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件事実関係の下においては」との留保を付した上で、正当防衛の成立を否定した原審の判断を正当としており、相手方による侵害を自ら招いた者が反撃行為をした場合に正当防衛が成立する余地を否定していない（最決平20.5.20）。判例の結論に賛成する学説は、防衛者自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す自招侵害の場合に、まず、原則として正当防衛が成立しない理由として、①防衛行為が社会的相当性を欠く場合には正当防衛を認めるべきでないとする社会的相当性説、②正当防衛の要件は満たしていても、全体として防衛行為とはいえない場合には正当防衛となり得ないとする防衛行為否定説等が対立している。そして、例えば、挑発行為が社会的相当性の枠をそれほど逸脱するものではなく、また、相手方の軽微な侵害が予測されるような挑発に対して、極めて重大かつ異常な法益侵害を伴う攻撃がなされた場合には、①反撃行為に社会的相当性が認められるとして、又は、②反撃が全体として防衛行為といえるとして、正当防衛が成立し得るとする。よって、相手方を挑発して相手方による侵害を自ら招いた者が、それに対し反撃した場合、正当防衛が成立する余地がある。

4 誤っている

最大判昭 23.7.7、最判昭 32.1.22。本記述では、いわゆるけんか闘争状態にある者が、相手方に対して加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地があるかが問題となる。この点、判例は、「互に暴行し合ういわゆる喧嘩は、闘争者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一団の連続的闘争行為であるから、闘争の或る瞬間においては、闘争者の一方がもっぱら防禦に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般からみては、刑法第 36 条の正当防衛の観念を容れる余地がない場合がある」として、けんか闘争の場合にも正当防衛が成立する余地があることを言外に示している（最判昭 23.7.7）。そして、この判旨について、その後の判例は、けんか闘争においても正当防衛が成立する場合がありますという法律判断を含むものと解している（最判昭 32.1.22）。判例の結論に賛成する学説は、一方の攻撃がそれまでの経過から見て新たな別個の侵害の開始と認められる場合や、攻撃が質的に急激に重大化した場合等について、①社会的相当性を逸脱しないこと、又は、②客観的に防衛行為といえること等を理由に、正当防衛の成立の余地を認めている。よって、いわゆるけんか闘争状態にある者が、相手方に対して加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地がある。

5 誤っている

最判昭 44.12.4。本記述では、反撃行為により相手方に与えた被害が、相手方の侵害から予想された被害よりも大きい場合に、正当防衛が成立する余地があるかが問題となる。この点、左手の中指と薬指をつかんで逆にねじあげられたのに対して胸の辺りを 1 回強く突き飛ばし、治療 45 日を要する頭部打撲症の傷害を負わせたという事案において、判例は、「やむを得ずにした行為」（36 条 1 項）とは、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであって、その反撃行為が右の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、法益衡量の原理に立脚する緊急避難とは異なり、正当防衛においては、防衛行為者には侵害者に対して優越的な地位が認められるから、防衛行為によって実際に生じた法益侵害が、それによって回避した法益侵害よりも、侵害性において大であっても、そのことによって、正当防衛の成立が否定されるものではないということを挙げるものがある。よって、反撃行為により相手方に与えた被害が、相手方の侵害から予想された被害よりも大きい場合に、正当防衛が成立する余地がある。